

1501651-50.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... em 23/06/2016), firmou o entendimento de que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos"; logo, "o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501651-50.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501651-50.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE BRANDÃO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. Kaique de magalhães rodrigues, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, em 14 de julho de 2022, por volta das 19h47, na Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 253, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros 36 (trinta e seis) invólucros plásticos contendo o peso líquido de 5,2g (cinco gramas e vinte centigramas) de cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2. Segundo consta na inicial acusatória, Policiais Militares realizavam patrulha ostensiva pela via pública mencionada no horário indicado, momento em que se depararam com KAIQUE, quem teria apresentado comportamento suspeito diante da presença da viatura policial, rapidamente adentrando em um estabelecimento comercial, o que motivou sua abordagem, sendo encontrada, em suas vestes, uma bolsinha, dentro da qual estavam as drogas discriminadas e a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais).

1.3. O Réu foi notificado (fls. 122) e ofertou defesa prévia (fls. 126/143), o recebimento da peça acusatória ocorreu em 15 de agosto de 2022 (fls. 145/146), oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Naquela solenidade foram ouvidas duas testemunhas e o Réu interrogado (fls.

170/174).

1.4. Encerrada a instrução criminal, a Ilustre Representante do Ministério Público de São Paulo pediu a procedência da ação penal, com o reconhecimento, em desfavor do Acusado de maus antecedentes e da reincidência, o que impediria a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, postulando, então, pelo início da execução da pena de reclusão, vedada sua substituição por pena restritiva de direitos, em regime fechado (fls. 177/182). A Douta Defesa, por seu turno, sustentou não ser o Réu reincidente específico, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de liberdade provisória, para que possa ele recorrer em liberdade (fls. 187/190).

É o relatório. Decido.

2. De início, destaco ser cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi firmada no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocinio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2.2. Apensar disto, no caso concreto dos autos, a atuação dos agentes policiais se deu após, segundo depoimentos dos Policiais Militares arrolados como testemunhas comuns, após visualizar o Acusado a viatura policial, acelerou o passo, demonstrou "nervosismo incomum" (fls. 3 e 4) e buscou entrar em um estabelecimento comercial nas proximidades. Dito de outro modo, no caso concreto em testilha, a abordagem do Réu se deu por agentes policiais em atividade de patrulhamento ostensivo, tendo sido descrita com concretude as circunstâncias que ensejaram a abordagem, não havendo que se reconhecer qualquer ilicitude da prova assim amealhada ou em relação às delas derivadas.

3. Superado isto, a pretensão punitiva estatal é procedente, porquanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 5/7, pelo auto de constatação de fls. 15/17 e pelo exame químico-toxicológico de fls. 167/169, corroborados pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre o Réu.

3.2. Com efeito, a testemunha Vagner Alex Moraes, Policial Militar, contou que estavam em patrulhamento, acabando de sair da Companhia, por volta das 19h30, visualizou o Réu sair de uma residência normalmente, percebendo a aproximação da viatura policial, "olhou várias vezes para trás", acelerou o passo e tentou adentrar a um bar. Foi realizada busca pessoal, em uma pochete foi confirmada a existência de drogas, consistentes em pedras de "crack", além de dinheiro, tendo sido confessado que receberia R\$ 150,00 para transportar os entorpecentes até uma passarela.

3.3. Vinícius Malveiro dos Santos, Policial Militar, em deslocamento, por volta das 18h00, visualizou KAIQUE acelerando o passo e ingressando num bar, o que levantou a suspeita da equipe. Abordando o Réu, foram localizadas drogas que seriam entregues a terceiro indivíduo. Foram encontradas 36 pedras de "crack" e aproximadamente R\$ 200,00 em cédulas diversas. Indagado sobre a origem dos entorpecentes, afirmou o Réu, naquela oportunidade, que seria entregue a pessoa desconhecida.

3.4. KAIQUE DE MAGALHÃES RODRIGUES, informado do seu direito ao silêncio, disse que conheceu um "rapaz" no ferro velho, quem lhe ofereceu um "trabalho", consistente em levar uma "mercadoria" até a "passarela". Diz-se arrependido, confessando os fatos imputados, porque necessitava complementar o aluguel do quarto de pensão, eis que precisava de R\$ 150,00 para complementar o aluguel.

3.5. Em todo caso, saliento que o flagrante é forma de demonstração de materialidade e autoria, eis que "duas são as justificativas para a existência da prisão em flagrante: a reação social imediata à prática da infração e a captação, também imediata, da prova" (in Vicente Grecco Filho, Manual de Processo penal, 11ª

edição, Ed. Saraiva, 2015, p. 313).

3.6. Outrossim, sobre a prova oral colhida em juízo, cabe frisar que em juízo os agentes policiais reiteraram o quanto narrado em sede policial (fls. 2 e 3) e que interesse algum teriam em prejudicar os Réus, imputando-lhes falsamente o cometimento de crimes tão graves. E "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3.7. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, consoante a própria confissão do Acusado, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas. Ademais, observa-se que a quantidade de substâncias apreendidas e a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, permitem o reconhecimento do delito acima.

3.8. Desta forma, a coligação das provas coligidas aos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - é apta a demonstrar a prática da conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Desta feita, sendo certa a materialidade delitiva, bem como a autoria por parte do Acusado, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à dosimetria da pena a ser imposta.

3.9. Na primeira fase da dosimetria, sobre a quantidade e natureza dos entorpecentes, nada há de especial relevância a justificar a elevação da pena-base, conclusão que pode ser estendida às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com exceção dos maus antecedentes (fls. 73/77). Com efeito, a pena decretada nos autos do processo nº. 0058923-15.2013.8.26.0050, pelo MM. Juízo da 22ª Vara Criminal do Foro da Capital, foi extinta em 17/02/2016 (fls. 75), mas "condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos do art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base acima do mínimo legal" (STJ, AgRg no RESp 1500382/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

3.10. Portanto, fixo a pena-base com acréscimo de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3.11. Na segunda fase, verifico que o Inculpado ostenta condenação criminal com trânsito em julgado nos autos dos processos nos. 0007155-71.2021.8.26.0502, 0011840-86.2016.8.26.0635, 0043210-29.2015.8.26.0050 e 0008539-87.2017.8.26.0606 (fls. 73/77). Levando em conta singelo critério aritmético, a pena intermediária deveria ser elevada em 4/6 (quatro sextos), mas é forçoso reconhecer, como circunstância atenuante, a confissão espontânea, sendo possível "a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Tema nº. 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

3.12. Observado que o Réu não ostenta condenação pretérita relacionada à traficância, a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea deve resultar em acréscimo de 2/6 (dois sextos), de modo que a pena intermediária deve resultar em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

3.13 Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, porque inviável a subsunção à espécie do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, haja vista a reincidência do agente e seus maus antecedentes criminais. Por conseguinte, fixo a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento 777 (setecentos e setenta e sete)

dias-multa, cada um no piso legal à míngua de elementos que indiquem a situação financeira do Increpado.

3.14. Apesar da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, porquanto “a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena” (STF, Habeas Corpus nº. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), o Acusado é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa, o que impede a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Sendo assim, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, a execução da pena corporal decretada, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve se iniciar no regime fechado.

3.15. Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no julgamento do HC nº. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 23/06/2016), firmou o entendimento de que “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”; logo, “o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa”. De seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça” (Pet nº. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado nº. 512 de sua súmula.

3.16. A despeito disto, à conduta típica a que condenado o Increpado não se subsume o privilégio acima aludido e a reincidência em crime doloso impede a substituição da reclusão por pena alternativa, restritiva de direito. Por sua vez, a quantidade aplicada de pena corporal inviabilizaria o sursis.

4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Kaique de magalhães rodrigues, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a se iniciar no regime fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, estes no valor mínimo legal.

4.2. Condeno, ainda, o Réu ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608/2003, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060/50.

5. Tendo o Increpado permanecido preso durante a instrução processual e “uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há de se cogitar no seu relaxamento ou revogação após prolação de sentença condenatória” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2215534-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016). Portanto, deverá o Réu permanecer preso preventivamente durante o processamento de eventual recurso.

6. Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências: (a) Comunique-se ao MM. Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, consignado-se as homenagens de estilo; (b) lance-se o nome do Acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal; (c) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao MM. Juízo da Execução Criminal, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84, não se olvidando das homenagens de estilo.

7. Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida,

comunique-se a respeito ao MM. Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Osasco, 20 de setembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA